

1501800-74.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1501800-74.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501800-74.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Guilherme Souza Lima Azevedo

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia em face de AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 25 de julho de 2021, às 09h27, na Rua Tibiriçá, 109, Jd. Santana, Município de Cajamar, AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA trazia consigo, 38 (trinta e oito) porções de Ecstasy; 397 (trezentas e noventa e sete) porções de maconha; 498 (quatrocentas e noventa e oito) porções de cocaína e 308 (trezentas e oito) porções de crack, substâncias capazes de causarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Convertida, em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva em 26/07/2021 (f. 71-74).

Laudo de exame químico de entorpecente acostado às f. 210-212.

A denúncia foi recebida em 02/09/2021 (f. 125-127), o réu foi regularmente citado (f. 147) e ofereceu defesa prévia (f. 152-163). Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (f. 213-215), prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que

foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram. Ministério Público e Defesa se manifestaram em alegações finais orais. É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA, pela prática dos fatos delituosos dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De fato, assiste razão ao Ministério Público.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (f. 1), boletim de ocorrência (f. 10-12), do auto de apresentação e apreensão (f. 13-14), do laudo preliminar de constatação da natureza tóxica (f. 16-21), do laudo pericial químico de entorpecente (f. 210-212), que atestou que as substâncias encontradas se tratavam de THC e cocaína, que são de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA.

Inquirida, a testemunha Luiz Carlos Caversan, guarda municipal, disse que se recorda dos fatos porque a ocorrência foi atípica. Em patrulhamento pela rua, visualizaram um indivíduo agachado, praticamente dormindo. Abordado, perceberam que portava uma mochila e uma pochete, ambas contendo vários entorpecentes. O local é conhecido pelo tráfico. Segundo informado pelo réu, virou a noite na prática do ilícito. A mochila estava nas costas e a pochete junto ao corpo do acusado.

Encontraram um rádio comunicador, as drogas, e 534 reais em notas fracionadas. Havia maconha, cocaína, crack. Não se recorda se havia ecstasy. A ocorrência foi atípica porque o réu estava dormindo. O acusado confessou informalmente que estava na venda das drogas. Não se recorda de ter abordado o réu em outras ocasiões. Não se recorda se o acusado afirmou ser usuário de drogas. Não foram avistadas outras pessoas no local. Havia uma fogueira, quase apagada. O réu não esboçou nenhum tipo de reação.

A testemunha Alonso Junio Barbosa do Carmo, guarda municipal, relatou que, em patrulhamento, depararam-se com o réu sentado, de cabeça baixa, dormindo, portando mochila e pochete. Após acordado e instado a tanto, abriu a mochila e a pochete, quando constataram a presença de vários entorpecentes, celular, rádio comunicador e 531 reais em notas fracionadas. Todos os objetos estavam com o réu, que confessou informalmente no momento da abordagem. Afirmou que havia pedra de crack, cocaína, maconha e ecstasy. A quantidade era grande, aproximadamente 2 quilos. O dinheiro estava em notas fracionadas. O rádio comunicador se prestaria ao contato com o olheiro. Não o conhecia anteriormente. Dormia porque certamente virou a noite no tráfico. O local é conhecido pela venda de drogas. Não mencionou se seria usuário. Não havia mais ninguém nas proximidades. Não se recorda exatamente onde estavam celular e o rádio comunicador, mas estavam em sua posse.

Interrogado, o acusado AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA disse que a acusação não é verdadeira. Relatou que foi comprar drogas e o vendedor correu, deixando os entorpecentes. Não estava no local dormindo ou cabisbaixo. Tinha só 20 reais e seu celular.

Por tudo que foi coligido nos autos, tem-se que a palavra do acusado encontra-se em absoluta dissonância do conjunto probatório, em especial das testemunhas que efetuarão a diligência de apreensão das substâncias.

De proêmio, destaco que o réu foi preso em flagrante, o que, segundo asseverado por José Frederico Marques, consubstancia a "certeza visual do crime" (MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Brookseller, 1997, v. IV, p. 175).

No mais, não há porque se desconfiar da palavra dos guardas municipais, que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção iuris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua

condição funcional" (RT 752/589).

Por essa vereda caminha também o entendimento do Eg. TJ/SP: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova" (TJSP; Apelação Criminal 0360928-92.2010.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2011; Data de Registro: 15/04/2011)

Ademais, os testemunhos foram prestados de forma harmônica e em uníssono, consubstanciando elemento suficiente para fundamentar um édito condenatório, quando aliado às demais provas presentes nos autos.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. Tanto não é possível exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Acrescento que a versão trazida pelo acusado é de todo fantasiosa e inverossímil, e restou ilhada dos elementos dos autos.

No mais, e com a devida vênia, reputo que não há nulidade nas diligências encetadas pelos guardas que possam macular as demais provas produzidas. Assim, deixo de acolher a tese suscitada pela combativa Defesa, o que faço com fundamento na jurisprudência do Col. STJ. Confira-se: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente 1. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019)".

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente transportar e trazer consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, o que ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No mais, é imperiosa a necessidade de o julgador estar sempre atento e dedicado às teses defensórias, no entanto, no caso em análise, as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

Com efeito, os elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo estão tranquilamente comprovados nos autos: a grande quantidade de entorpecente (397 porções de maconha; 498 porções de cocaína e 308 porções de crack); o modo de acondicionamento (porções embaladas individualmente, prontas para o comércio); o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de tráfico de entorpecentes); revelam que se tratava sim da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06. E pela lição de Júlio F. Mirabete, "indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque o réu ostenta maus antecedentes (f. 53) e a grande quantidade e lesividade das substâncias encontradas impõe uma elevação na pena, razão pela qual fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, resultando-se em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (f. 53), razão pela qual promovo um aumento de 1/6 às penas, resultando-se em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase de cálculo penal, considero inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o legislador do texto da referida norma quis favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos. Destarte, torno definitivas as penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, à míngua de outros elementos modificadores.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas, uma vez que o réu demonstrou ter condições econômicas para arcar com tal valor.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu e altíssima quantidade de substância entorpecente apreendida.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/12, por se tratar de hipótese de progressão de pena que, pelo nosso ordenamento jurídico, requer a análise cumulativa do requisito subjetivo, o que não é possível neste momento processual.

E, pelos mesmos motivos já explanados, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para CONDENAR AUGUSTO GUTEMBERG JOTA DA SILVA, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do CPP, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que persistem os temores autorizativos da prisão cautelar, devendo o Estado precaucionar-se a fim de garantir a manutenção da ordem pública, sobretudo pela reincidência e elevadíssima quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a denotar periculosidade concreta. Afinal, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci ("Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930), "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação".

Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra, cabendo a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão, nos termos do artigo 431, §1º, da NSCGJ.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de

reparação dos danos causados pela infração e ausência de pedido.

Condene o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.

Com o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se a guia de recolhimento provisória, bem como carta de guia.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido e expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada; Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

Cajamar, 5 de abril de 2022.